

# 第 69 問

暴力団の幹部組員甲は、ほかの組員らと共同して A を殺害するつもりであったが、事前に、甲の弟分である別の組員乙に対し、「自分が警察に捕まったときには、乙が真犯人だと名乗り出て、自分が釈放されるようにしてほしい」と頼んだところ、乙はこれを承諾した。その後、甲は、計画どおり A を殺害し、その事件の被疑者として逮捕され、警察署に留置された。

- (1) 乙は、甲に言われるとおり、警察署に出頭して、真犯人は自分であると申し出たが、乙が犯人であることをうかがわせるような証拠がなかったため、乙の申し出にはとりあわず、甲は釈放されなかった。

甲と乙の罪責を論じなさい。

- (2) 他方、捜査当局は、同じ事件の共犯者として B を指名手配していたが、丙は、B が事件当日自分と行動を共にしており無実であると知っていたので、B に隠れ家を提供してかくまった。

丙の罪責を論じなさい。

(一橋大学法科大学院 平成 17 年度)

## 第1 小問(1)について

### 1 甲の罪責

- (1) Aに対する殺人罪(199)が成立するのは当然である。
- (2) 次に、乙に対する犯人隠避罪(103)の教唆犯(61I)の成否が問題となる(【論点】犯人が自らの蔵匿・隠避を他人に教唆した場合の教唆犯の成否【編】旧H9-2)。この点について、可罰的に解するのが判例(大判昭8.10.18)である。

総合 284 頁 論証 149 頁

なお、甲を教唆犯ではなく、共同正犯と見た場合については、判例がない。学説では、教唆犯の場合の理由付けを転用して可罰的であるとする見解と、類型的な期待可能性を考慮し、正犯処罰が構成要件上排除されているとして不可罰であるとする見解が対立している。

### 2 乙の罪責

犯人隠避罪の成否が問題となる(【論点】身代わり犯人の出頭(犯人の身柄拘束後の場合))。この点については、甲が既に身柄を拘束されているので、それでも同罪が成立するのか、論じなければならない。判例(最決平元.5.1【百選Ⅱ122】)は、「刑法103条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定であって……、同条にいう『罪ヲ犯シタル者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう『隠避』に当たると解すべきである」(下線部は担当者)として、犯人の身柄拘束後であっても可罰的であるとしている。

総合 283 頁 論証 150 頁

## 第2 小問(2)について

- 1 丙は甲の共犯者として追われているBをかくまっているので、犯人蔵匿罪の成否が問題となる(【論点】「罪を犯した者」(103)の意義)。真犯人ではない者を蔵匿した場合であっても、犯人蔵匿罪は成立するのか。
- 2 この点について、「刑法第103条は司法に関する国権の作用を妨害する者を処罰しようとするのであるから、『罪ヲ犯シタル者』は犯罪の嫌疑によって捜査中の者をも含むと解釈しなくては、立法の目的を達し得ない。」として、肯定的に解するのが判例(最判昭24.8.9【百選Ⅱ117】)であるから、丙には犯人蔵匿罪が成立する。

総合 283 頁 論証 148 頁

## 答案構成

### 第 1 小問(1)

#### 1 乙の罪責

犯人隠避罪（103）の成否

↓

犯人の身柄拘束後の身代わり行為に、犯人隠避罪が成立するか

↓

可罰説

↓

犯人隠避罪成立

#### 2 甲の罪責

殺人罪（199）成立

↓

犯人隠避罪の教唆犯の成否

↓

可罰説

↓

犯人隠避罪の教唆犯成立

### 第 2 小問(2)

#### 1 犯人蔵匿罪の成否

↓

#### 2 「罪を犯した者」の意義

↓

真犯人に限られず、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者を指す

↓

#### 3 あてはめ

↓

犯人蔵匿罪成立

## 第1 小問(1)

## 1 乙の罪責

(1) 乙が殺人の罪で既に身柄を拘束されている甲の身代わり犯として出頭した行為について、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」を「隠避させた」ものとして、犯人隠避罪(103条)が成立するか。

(2) 同条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定である。

そうだとすれば、「罪を犯した者」には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれるというべきである。

したがって、甲はすでに身柄を拘束されているものの、「罪を犯した者」に当たる。

また、「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいうと解すべきであるから、犯人として逮捕勾留されている者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう「隠避」に当たると解すべきである。

したがって、乙が、甲が犯人として身柄を拘束された後に、身代わり犯として出頭した行為も「隠避」に当たる。

なお、このような本罪の罪質に鑑みれば、本罪は抽象的危険犯というべきであるから、警察が乙の申し出に取り合わなかったことは本罪の成否に影響を及ぼさない。

(3) 以上から、乙には上記についての認識もあるから、故意(38条1

1

項)に欠けるところもなく、犯人隠避罪が成立する。

## 2 甲の罪責

(1) 殺意をもってAを殺害した行為には、殺人罪(199条)が成立する。

(2)ア 次に、乙に身代わり犯として出頭することを依頼し、乙に上記行為を行わせた点について、乙に対する犯人隠避罪(103条)の教唆犯(61条1項)の成立が考えられる。

イ ここで、103条の犯罪の主体には犯人は含まれない。条文上「させた」となっているし、犯人には適法行為の期待可能性がないからである。このことに着目し、より犯情において軽い教唆犯は成立しないと解する立場がある。

この立場によれば、甲に犯人隠避罪の教唆犯は成立しない。

しかし、共犯の処罰根拠は、正犯を介した間接的な法益侵害に求められるところ、正犯に犯罪が成立する以上、これを教唆すれば法益侵害を引き起こしているといえることができる。

しかも、他人を利用して自己を隠避させることは、自ら隠避するよりもそれが容易になるから、その意味で法益侵害の程度はより高い。

また、このような事態にあっては、定型的に期待可能性がないといえることはできないし、他人を利用して隠避を図ることは防御権の濫用である。

以上の諸点からすれば、犯人が他人に隠避を教唆した場合は、教

2



唆犯が成立するとみるべきである。

ウ したがって、甲には犯人隠避罪の教唆犯が成立する。

## 第2 小問(2)

1 丙は、甲の殺人の共犯者として追われているBをかくまっているので、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者……を蔵匿」したものととして、犯人蔵匿罪の成立が考えられる。

2 もっとも、Bは真犯人ではなく、捜査機関に嫌疑をかけられているにすぎない。では、このような者も「罪を犯した者」に含まれるか。

この点について、被疑者の蔵匿・隠避は、捜査活動を妨害するものであり、ついには真犯人かどうかさえも不明にさせるおそれがあることは否定できない。

このようなおそれがあれば、犯人蔵匿罪・隠避罪の保護法益たる国家の刑事司法作用は害されるというべきである。

したがって、「罪を犯した者」については、真犯人に限られず、犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者を指すと解すべきである。

3 本問でも、真犯人ではないBも、甲の共犯者として指名手配され嫌疑をかけられている以上、「罪を犯した者」に含まれる。

また、丙はBは真犯人ではないと考えているものの、甲の共犯者として指名手配され嫌疑をかけられている認識はあるから、故意(38条1項)を阻却することもない。

以上から、丙に犯人蔵匿罪が成立する。

以上